

1501175-82.2021.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAROLINA MOREIRA GAMA

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/02/2022

... REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE. JUSTA CAUSA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. É pacífico, nesta Corte, o entendimento de que, nos crimes permanentes, tal qual o tráfico de drogas, o estado de flagrância se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

1ª Vara Criminal

Rua. Alice Alem Saad nº. 1.010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501175-82.2021.8.26.0530 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501175-82.2021.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2130120/2021 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 17883614 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO,

2403/21/919 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2130120 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3,

2403/21/919 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DARIO JUNIOR DA SILVA DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA MOREIRA GAMA

Vistos

DARIO JUNIOR DA SILVA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, c.c. 40,III, da Lei n. 11.343/06, porque em 12 de maio de 2021, por volta das 19 horas, na Rua Antonio Castania Filho, n. 115, Jardim Paiva, nessa cidade e comarca, guardava e tinha em depósito, para entrega e consumo de terceiros, mediante venda, 295,550g da substância popularmente conhecida como maconha, na forma de 221 porções, bem como 140,248g da substância conhecida como cocaína, essa em 533 cápsulas do tipo eppendorfs, agindo ele sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,

Determinou-se a notificação do réu para defesa escrita preliminar, na forma da lei especial e, tudo cumprido (pags. 105 e seguintes), ocorreu que a denúncia foi

recebida em 10 de setembro de 2021 (pag. 119/121).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, a prova oral foi colhida e o acusado foi interrogado ao final, tudo pelo sistema TEAMS (pags. 149/150)..

Encerrada a instrução sem oposição das partes, a Acusação, em debates, requereu a procedência da ação penal, quando inclusive fez alusão aos últimos julgados do STJ que se referem à autorização para o ingresso da polícia, insistindo que no caso o flagrante prevalece e justifica a condenação.

A Defesa, em debates, pugnou pela nulidade da prova da materialidade justamente por conta dos tais meios da apreensão, indicando contradições entre os depoimentos dos policiais e falta de justa causa para a devida abordagem, citando também julgados recentes do STJ. Subsidiariamente, fez referências a eventual dosagem de pena, sob redução pela confissão.

É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Do meticoloso cotejo do conjunto probatório, verifico que razão assiste à Defensoria: as contradições colhidas na prova oral somadas à falta de outras provas a respeito de dita conduta suspeita ou ilícita do denunciado, em necessária justa causa, restaram incontornáveis.

Antes, contudo, desse exame aprofundado sobre as circunstâncias da prisão, para o fundamento que nos convenceu da improcedência nesse caso, registro que a materialidade partiu do auto de prisão em flagrante, do de exibição e apreensão de pag. 09 – que se refere à apreensão de R\$ 194,00; 386 gramas de cocaína e 339 gramas de maconha –, além do que incluído nos laudos de pags. 39/41 e págs. 91/93. Esses concluíram pela detecção das substâncias ativas dos entorpecentes mencionados.

Aliás, nem mesmo o próprio réu, como se verá e ao ser interrogado, negou a realidade daquela apreensão, ou seja, de tudo o que encontrado de ilícito no interior do seu quarto, chegando até a admitir que vinha guardando algumas das tais substâncias para terceiros – e disse se poderia também concluir pela finalidade ínsita do delito de tráfico.

Por outro lado, a prova oral trouxe um cenário de dúvida inadmissível para a condenação, ou seja, quando aspectos relacionados à legalidade do ingresso dos policiais não podem ser simplesmente relegados.

Em Juízo o policial Feitosa explicou que primeiro se depararam com o réu na parte de fora da própria residência dele, informando que, assim que o mesmo se deu conta da presença dos agentes, pôs-se em fuga para dentro da casa, para onde correu e restou perseguido e detido. Esse policial esclareceu que, a partir disso, e mesmo realizando a parada do réu já no interior da residência, tornaram a levá-lo para fora e ali, e não dentro da casa, realizaram a revista pessoal, mas nada foi encontrado.

Já nesse ponto há divergência relevante com a palavra do outro condutor, ou seja, o outro ouvido, policial Felipe, nunca declarou que o réu correu para o interior da residência, de onde foi trazido dali de volta: disse que o réu foi abordado logo ali do lado de fora, nunca se referindo ao fato de que chegou a ser alcançado no interior da casa dele.

Indo adiante, apenas o policial Feitosa referiu-se a um elemento a mais que pudesse justificar a ação contra o réu: disse que foram feitas pesquisas de praxe e daí tomaram conhecimento de que o réu já tinha “passagens” por tráfico e, apenas depois

portanto, o indagaram se havia algo de ilícito no local, quando o réu negou, mas teria, segundo o depoente, autorizado a entrada da polícia.

Segundo o policial Feitosa disse mais de uma vez, ingressaram no local não só sob autorização do abordado, mas também de mais outra, da proprietária do imóvel e mãe do réu, que para eles deixou claro que não concordava com algo de ilícito que o filho pudesse estar fazendo ali, onde também moravam outras mulheres da família. Disse até que essa testemunha, proprietária da casa, foi qualificada e indicada em BOPM, mas também respondeu que não houve outra prova, além de depoimentos do flagrante ou relatório da própria polícia, da autorização para ingresso e revista no interior da casa.

Enfim, o referido policial Feitosa deu conta de como, no quarto do réu, encontraram e apreenderam os entorpecentes, retomando que os eppendorfs de cocaína vinham em uma caixa de uísque vazia, enquanto que a maconha estava em sacola plástica, além de dinheiro perto desta. O réu, para eles e pelo menos naquele momento, admitiu ser o proprietário ou único responsável pelos ilícitos.

Como já indicado aqui mesmo antes, nem tudo do depoimento do tenente corresponde a aspectos declarados pelo policial Felipe Alves. Esse nem se lembrou de ter sido realizada consulta que pudesse indicar que o réu tivesse, por seus registros, alguma ligação com o tráfico local, cogitando que outro parceiro pudesse ter assim constatado.

Os dois policiais ainda confirmaram a indagação da Defensoria sobre terem partido para o local por conta de um patrulhamento de rotina, ou seja, não tinham alguma informação prévia ou específica da conduta do réu. E realmente, sobre a autorização de ingresso, ambos reiteraram que tudo a respeito constou do boletim de ocorrência, repetindo que a mãe do réu, além dele, também lhes autorizou entrada e vistoria.

Contudo, foi ouvida justamente, em Juízo e como informante, a genitora do réu, ocasião em que ela reiteradamente negou ter autorizado o ingresso naquela residência. Essa testemunha chegou a nos dizer que se assustou ao se deparar com um dos policiais já dentro da sua casa, no recinto da cozinha. Declarou que assim que isso ocorreu foi imediatamente para fora, seguindo de volta o policial, daí verificando que seu filho estava ali detido e algemado, contra a parede em uma casa do lado da sua. Depois respondeu que voltou para dentro de sua casa e, em nenhum momento, foi consultada sobre os policiais reingressarem e vistoriarem ali, ou seja, insistiu no fato de que eles simplesmente assim o fizeram, levando seu filho para o quarto.

O réu, de seu lado, disse quase mesmo, partindo da descrição de sua rotina daquela tarde: explicou que, ao voltar para a casa de carro, e assim que estacionou, foi imediatamente abordado, alegando que não correu, e sim os policiais já lhe indagaram se ele tinha passagem por tráfico e ainda disseram que havia mandado expedido contra ele. Daí reiterou que em nenhum momento autorizou o ingresso dos policiais em sua casa e, mesmo assim, eles o fizeram. Por fim, como adiantado e a partir disso, o réu nem contestou a maior parte do resultado da apreensão.

Nesse ponto vale a ressalva de que, como bem aduziu a Acusação em debates, mesmo ao se confrontar os depoimentos com a própria versão judicial do réu, e até do que ele em grande parte se dispôs a confessar, não se conclui exatamente que os policiais vieram dispostos a mentir ou a falsear algo apenas para consagrar a incriminação. Na verdade até se pode mesmo conceber que o acusado, disposto à absolvição, ou sua genitora, pelo parentesco com ele e na condição de informante, possam ter ditado circunstâncias diversas para o que de fato ocorreu.

Contudo, mesmo a par disso, o que nos faz endossar o pedido de absolvição da Defesa técnica decorre diretamente das citadas decisões dos Tribunais Superiores de nosso

país. É que, na contrariedade de uma palavra com outra, na falta de certeza a respeito de circunstâncias primordiais da legalidade do flagrante e da correspondente apreensão, é a prova da acusação que padece.

Também anoto que esse mesmo Juízo, tantas vezes antes, entendeu de forma diversa, firmando a condenação de outros processados em circunstâncias similares, reconhecendo que vinham legal ou lícitamente flagrados em delitos permanentes.

Mas agora, em posição que se deve adotar, endossando-a aqui, Turmas penais do STJ unificaram o entendimento sobre a necessidade de prova de autorização do morador para ingresso da polícia nesse tipo de caso, como bem suscitado pela Defensoria.

Não só a Sexta Turma do STJ, mas também a Quinta do mesmo Tribunal vem ratificando o entendimento de que cabe ao Estado demonstrar, de forma inequívoca e inclusive por meio de registro escrito e de gravação audiovisual, o consentimento expresso do morador para entrada da polícia em sua casa - isso evidentemente, na falta de ordem judicial. Tais decisões vem se acumulando para casos de tráfico de drogas, ou seja, ainda que considerada a natureza permanente desse delito, ainda que à vista de determinado resultado da apreensão, sob quantidade de droga na residência do abordado.

Tanto aqui, como naqueles casos que consagraram a improcedência de ações penais da mesma ordem, os policiais não foram capazes de providenciar provas específicas, que deveriam salvaguardar a licitude de suas diligências, como a do ingresso sob registro detalhado, com autorização por escrito, firmada ou até filmada, de morador, a indicação de testemunhas, a impossibilidade de ser suspensa aquela imediata ação da polícia para o subsequente pedido por mandado judicial, etc. Mais: se o réu já era tido como suspeito, ou até por conta de seus registros antecedentes, certamente que os policiais poderiam tudo relatar aos seus superiores para a obtenção do respectivo mandado.

Sobre a existência de fundadas razões para o ingresso dos policiais, no caso de não provada, como aqui, a autorização do morador, as mesmas Superiores Instâncias já avaliaram que tais razões não podem decorrer de denúncia anônima ou de mera suspeita, mas de investigação específica da polícia por meio de campana, filmagem, fotos, essas dando conta, por exemplo, de movimentação não usual no interior da residência, sob alguma evidência concreta de que a residência vinha usada para o delito. Outros casos são cancelados, para o ingresso, pelos mesmos julgados, ou seja, há licitude do ingresso da polícia quando ninguém mora no local, se há notícia de disparo de arma de fogo, se é percebido odor de determinada droga, se existe alguém em risco, etc. De novo, no caso em análise, nesse processo penal, faltou-nos aquele relevante elemento que poderia ser trazido pelos agentes policiais de modo a justificar seus ingressos naquele horário, quando não provada a autorização do réu, ou de outro morador, para tanto.

Apenas como reforço, vale a indicação de que, embora muitos julgados ainda estejam sendo proferidos em sentido oposto ao que aqui se adota, contamos já com precedentes também do próprio E. TJSP, como nos fundamentos de Acórdãos proferidos, por exemplo, na Apelação Criminal n. 000002387.2019.8.26.0548, da 12ª Câmara de Direito Criminal, ou nos da Apelação n. 1500329.36.2019.8.26.0530, da 13ª Câmara de Direito Criminal, entre outros.

Aliás, vale aqui a transcrição desse seguinte trecho proferido no Habeas Corpus n. 2285840-28.2021,8.26.0000, em Acórdão julgado pela 12ª Câmara de Direito Criminal do TJSP:

“Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em

fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE nº 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe: 8/10/2010). Com efeito: a) o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, embora tenha confirmado que a Constituição Federal dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito e, no crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo, ponderou a necessidade de demonstração prévia de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida; b) em razão do caráter permanente do delito de tráfico de drogas, o flagrante é possível a qualquer momento, não constituindo ilegalidade o ingresso dos policiais na residência, mesmo sem mandado de busca e apreensão, pois a regra constitucional da inviolabilidade do lar não socorre agente em situação flagrancial; c) no julgamento do RE 603.616/RO, todavia, o Excelso Pretório fixou a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. O crime de tráfico de drogas na modalidade atribuída ao ora paciente (guardar) possui natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial (o que não se deu na hipótese presente).

Nesse sentido, entre outros, o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça: - "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE. JUSTA CAUSA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É pacífico, nesta Corte, o entendimento de que, nos crimes permanentes, tal qual o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protraí no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que naquele momento, dentro da residência, haveria situação de flagrante delito. 2. Tendo o ingresso em domicílio decorrido de investigações preliminares, dando conta da existência de traficância na residência da recorrente, não há falar em nulidade do flagrante. 3. A análise de eventual validade das declarações prestadas por testemunha, que teria sido obrigada a prestar informação falsa sobre o delito, exigiria revolvimento fático-probatório, providência inadmissível nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido". (AgRg no AREsp 1.512.826/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020 - destacamos).

No caso concreto, os policiais ingressaram na residência, sem realizar qualquer tipo de investigação, sem consentimento do morador e sem situação de flagrante delito, o que, a meu ver, contraria a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio (...)

(...)

Diante desse contexto, tenho que a forma como os agentes públicos entraram na casa onde estava o paciente, sem qualquer investigação prévia, não constitui fundamento suficiente para autorizar a conclusão de que havia uma situação de flagrante delito, ainda que tenham sido encontradas e apreendidas drogas no quarto do

paciente; não havia suspeita fundada de que naquele momento e local estava sendo cometido algum tipo de delito, permanente ou não.

Nesse sentido, e em situação bastante semelhante à dos presentes autos, recentemente decidiu a Quinta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA 280/STF. FUGA ISOLADA DO SUSPEITO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DE PROVAS CONFIGURADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. No RE n.º 603.616/Tema 280/STF, a Suprema Corte asseverou que a flagrância posterior, sem demonstração de justa causa, não legitima o ingresso dos agentes do Estado em domicílio sem autorização judicial e fora das hipóteses constitucionalmente previstas (art. 5º, XI, da CF). 2. Apesar de se verificar precedentes desta Quinta Turma em sentido contrário, entende-se mais adequado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento que exige a prévia realização de diligências policiais para verificar a veracidade das informações recebidas (ex: "campana que ateste movimentação atípica na residência"). 3. Recurso em habeas corpus provido para que sejam declaradas ilícitas as provas derivadas do flagrante na ação penal n.º 0006327-46.2015.8.26.0224, em trâmite no Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP." (RHC 89.853/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020 destaque nosso)" (grifei).

Por fim, avalio relevante dizer que, a princípio e pelo que produzido para os autos, não há flagrante abuso ou excesso da equipe policial porque atuou de acordo com orientações que certamente se propagam ainda hoje, quando ainda são recentes as decisões precitadas e que invalidam apreensões sob aquele formato. Aos policiais, como se sabe, faltam treinamento e aparelhamento para situações desse tipo, e tanto que também naqueles habeas corpus de casos análogos já concedidos pelo STJ houve determinadas providências em prol da polícia militar, inclusive para a aquisição e distribuição de equipamentos eletrônicos, visuais ou de gravação, para a prova da exigida autorização do morador.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia e, como consequência, ABSOLVO DARIO JUNIOR DA SILVA DOS SANTOS, como incurso no art. 33, c.c. 40, III, da Lei n. 11.343/06, o que faço com fundamento no art. 386, II, do CPP.

Como consequência da absolvição, também determino a imediata expedição do alvará de soltura ao réu, cumprindo-se com urgência com o que necessário a tanto.

A despeito da absolvição, pelo seu fundamento e da ilicitude inerente ao que apreendido, decreto o perdimento da substância ilícita, apenas se liberando, em prol do réu, o respectivo numerário também então apreendido.

Também determino que se encaminhe cópia da presente decisão ao Comando Superior da Polícia Militar para que possa ter ciência do nosso entendimento e de meios que possam ser adotados para provas fundamentais relacionada a ações desse tipo, tudo com base também no que determinaram as Instâncias Superiores, do STJ, conforme julgados já mencionados aqui antes.

P . I . C .

Ribeirão Preto, 07 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA